

1501862-38.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2259689/2021 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Igor Rodrigo do Nascimento

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

IGOR RODRIGO DO NASCIMENTO, qualificado às fls. 07 e 17/18, está sendo processado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501862-38.2021.8.26.0537 - Controle nº 2021/001376

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2259689/2021 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Igor Rodrigo do Nascimento

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

IGOR RODRIGO DO NASCIMENTO, qualificado às fls. 07 e 17/18, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 porque no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 17h00, no escadão situado na Rua Platina, altura do nº 358, Taboão, nesta cidade de Diadema, trazia com ele e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 13 embalagens contendo 15,2g da droga cocaína, 41 embalagens contendo 15,1g da droga cocaína, na forma de crack, e 48 embalagens contendo 70,1g da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 08/09 e laudo de constatação provisória de fls. 13/15, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fl.41/43), foi apresentada defesa inicial às fls.124/128 pela d. Advogada constituída. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 03/12/2021 (fl.179) e certificada a notificação e a citação positiva do Réu (fls. 173). Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu ao final. Encerrada a instrução sem requerimento de diligências, seguiu-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação da pena base acima do mínimo diante da quantidade e nocividade da droga cocaína, concordando com a redução da pena no patamar intermediário, mas não também por sua substituição pela pena restritiva de direitos, fixando-se regime prisional semiaberto, sem possibilidade de recorrer em liberdade, e sim de vedação do apelo em liberdade.

Já a d. Advogada reiterou o pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, com a atenuante da confissão, com o redutor da pena e sua substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime prisional aberto e possibilidade de recurso em liberdade, concedendo-lhe a justiça gratuita. É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fl.10, nos laudos de constatação e no definitivo (fls.13/15 e 202/204), ambos positivos para as drogas maconha e cocaína.

A autoria é incontestada não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais civis (fls.05/06) o local é ponto de venda de entorpecentes. Dirigiram-se ao local. No final da via avistaram um indivíduo com uma sacola preta na mão, em atitude suspeita. Após a abordagem, identificado como Igor Rodrigo do Nascimento, encontraram em busca pessoal dentro da sacola, 13 papérolas aparentando ser cocaína, 41 papérolas aparentando ser crack e 48 papérolas aparentando ser maconha, e no bolso da calça a quantia de R\$81,00. Questionado, Igor confessou aos policiais estar ali comercializando os entorpecentes.

Sob o crivo do contraditório os policiais Lucas Barbaty e Marcelo Rosseto reiteraram que no local dos fatos, ponto de venda de drogas já conhecido, com notícia de que o tráfico continuava, e foram diligenciar a pé. No final da via avistou um indivíduo com uma sacola na mão. Suspeitaram ser o denunciado, ora réu,

que foi detido de costas, tendo ele se assustado. Ele estava sozinho. Na sacola preta que estava na mão do réu, localizaram as drogas (crack, cocaína e maconha) além do dinheiro. O réu confessou que estava ali traficando. O reconhecem como sendo o traficante detido.

O réu, em solo policial (fl.07), confessou estar ali vendendo os entorpecentes e que a quantia que estava em seu bolso era proveniente da mercancia dos entorpecentes.

Em juízo o acusado alegou que tinha saído cedo de casa para procurar serviço porque tinha acabado o gás em sua casa, mas não conseguiu, e por ter irmãos pequenos precisando fazer comida para eles, uns caras falaram que iam lhe ajudar se ele vendesse drogas. Foi a primeira vez que fez isso. As drogas eram só 12 maconha e 15 cocaína, não tinha crack, e o dinheiro era seu para comprar o gás e faltava pouco para completar os cento e vinte reais. Já tinha vendido drogas para umas três pessoas. Está arrependido, pois sempre trabalhou fazendo carreto, e passou a fazer bicos.

Logo, o interrogatório com a confissão do acusado, que não é prova única, pois veio corroborada pelos depoimentos dos testemunhos - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais.

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna com o verbos nucleares trazer consigo e transportar, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração.

Afasto tese de estado de necessidade, pois os bens jurídicos são desproporcionais, por se colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade, em detrimento do interesse individual, além de se tratar de crime de perigo abstrato. Ademais, não há prova nos autos de que o réu passasse por miserabilidade extrema a ponto de ter que violar a lei para sobreviver, dado que dificuldade financeira não autoriza ninguém a praticar delitos, assim como a falta de emprego não serve de causa excludente de ilicitude sob pena de se legalizar a prática de crimes por todo desempregado - o que não é aceitável.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza da droga (cocaína), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o numerário apreendido (fl. 52), são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito, mas principalmente pela grande quantidade do narcótico apreendido (102 invólucros totais), às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo: 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes e sim a atenuante da confissão, e tendo sido utilizado o interrogatório como meio de prova de autoria para a fundamentação do presente decreto condenatório, milita em seu favor a atenuante genérica prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, a reduzir a pena ao mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa), não podendo ir além

disso consoante Súmula 231 do STJ.

Em terceira etapa, não concorrem causas de aumento de pena. Quanto ao privilégio previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, o Réu faz jus ao beneplácito legal, porquanto seja primário (fls.26/27), mas considerando a natureza da droga cocaína e crack, de alto poder viciante e degradante da saúde humana, e o numerário apreendido (fl. 10 e 52), proveniente de vendas de drogas como por ele confessado em solo policial e reiterado hoje, quando afirmou ter feito pelo menos três vendas a usuários, demonstrando efetiva disseminação do vício e, portanto, maior envolvimento com a traficância, opto pelo percentual da metade, totalizando 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo atual tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

Contudo, incabível a benesse do art. 44 do CP, não se mostrando suficiente nem eficaz à reprovação da conduta do agente, menos ainda socialmente recomendável sob pena de potencializar a sensação de insegurança e intranquilidade social, a merecer maior reprovabilidade a conduta, dado que viola mais intensamente o bem jurídico tutelado, somado ao elevado número de ocorrências de tal natureza conferindo constante desassossego à sociedade, a exigir firme repressão do Estado como forma de desestimular o crime, geralmente cometido graças ao nível de organização próprio daqueles que fazem do tráfico seu meio de vida. Não bastasse isso: O artigo 44, caput, da Lei de Drogas veda, expressamente, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37. Já o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, que prevê uma causa de diminuição de pena, também estabelece, no caso de sua aplicação, que a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direitos. Ainda, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não ser possível a aludida substituição para o condenado por tráfico de drogas e condutas correlatas (artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37), bem como quando da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (HC 144.915/MG, Rel. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010. No mesmo sentido – STJ – HC 136.618/MG, 5ª t., Rel. Min. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010). ... Ora, não nos parece razoável proceder a substituição para autor de crime de suma gravidade. A personalidade, a conduta social e culpabilidade do traficante de drogas e de quem de qualquer forma o auxilia, bem como as consequências do crime, que são nefastas para o viciado e usuário e para a sociedade, não recomendam a substituição, que pode ser indeferida nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Ressalte-se, por fim, que a droga é o câncer que assola a todo o mundo já que, direta ou indiretamente, é responsável por boa parte dos crimes violentos que o afligem. Por causa dela as pessoas matam ou são mortas. É muito difícil um crime violento não ter a droga como estopim. Ou o agente está sob seu efeito, ou é vítima de um traficante ou de um drogado, ou é um traficante que mata um rival etc. Enfim, a droga, de uma maneira ou de outra, está ligada aos crimes mais graves.

A teor do disposto nos artigos 33, do Código Penal, fixo o regime prisional semiaberto, considerando a preponderância da natureza e da quantidade da droga, como visto antes, mais de cem porções, entre cocaína e crack, não ficando o juiz obrigado a fixar regime inicial relacionado unicamente com o quantum da pena, podendo optar por um mais gravoso ao observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006. Veja: Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional.” (AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019)

Por isso, ainda, vedo o recurso em liberdade. Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão

ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, estando desempregado, sendo incongruente soltá-lo quando ora condenado a regime que o manterá no cárcere. Ora: (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Reconheço a custódia cautelar do Condenado desde a data do fato, sem reconhecer-lhe direito à detração penal ou à progressão de regime, tendo em vista os critérios legais objetivos e a falta de atestado de bom comportamento carcerário atualizado. Assim, deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Ademais, ele está preso há menos de seis meses, sem direito sequer à progressão de regime.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra IGOR RODRIGO DO NASCIMENTO, qualificado às fls. 07 e 17/18, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e o faço para condená-lo à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 250 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos corrigido monetariamente à data do pagamento.

Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, em 100 Ufesp, já que assistido por Advogada particular e não juntou até a presente data declaração e comprovação de hipossuficiência.

O acusado não poderá apelar em liberdade. O recomendo no cárcere compatível com o regime ora fixado.

Decreto a perda de valores apreendidos nestes autos (fl. 52), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06. Ficando desde já autorizada a incineração dos entorpecentes.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal,

encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, intime-se o réu a paga-la em 10 dias e em 60 dias pague as custas processuais, sob pena de extração de certidões da Sentença para a Procuradoria Geral do Estado (dívida ativa).

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA